

בפני כב' המפקחת על רישום מקרקעין אסתי
שחל

נציגות הבית המשותף ברח' אריק לביא 3, נתניה
ע"י ב"כ משרד גיא קונפורטי ושות'

התובעת

- נ ג ד -

חברת קרן פז לבניין בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד גל נהיר שפר ואח'

הנתבעת

פסק דין

1. עניין לנו בתביעה למתן צו עשה אשר יורה לנתבעת להסיר את שלטי הפרסום אותם הציבה על גבי קירותיו החיצוניים של הבית המשותף שברחוב אריק לביא 3, נתניה הידוע כגוש 9042 חלקה 9 (להלן: "הבית" או "הבניין"), ולהשיב את המצב לקדמותו. כן התבקש לחייב את הנתבעת לשלם לתובעת דמי שימוש ראויים בגין השימוש האמור.
2. התובעת היא נציגות הבית (להלן: "התובעת" או "הנציגות"). הנתבעת היא החברה הקבלנית שבנתה את הבית, והיא נותרה הבעלים של מספר דירות בבית.
3. הבית טרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים, ואולם אין מחלוקת בין הצדדים כי הוא ראוי להירשם ככזה.
4. טענות התביעה יפורטו להלן בתמצית:
 - א. התובעת מונתה כנציגות הבית ביוני, 2016, ועוד טרם מינויה הציבה הנתבעת שלט פרסום למכירת דירותיה;
 - ב. לאחר שמונתה הנציגות הציבה הנתבעת שלט פרסום נוסף, ללא תיאום עמה תוך קידוח בגג ובקירותיו החיצוניים של הבניין; ביום 24.4.17 התקבלה החלטה ע"י הנציגות האוסרת על תליית שלטי פרסום ברחבי הבניין, ועל הסרתם של כל השלטים שנתלו; על אף שהחלטה זו נתלתה בלוח המודעות של הבניין, לא הסירה הנתבעת את שלטיה; פניות התובעת לנתבעת להסרת שלטי הפרסום לא הועילו; הנתבעת התעלמה מפניותיה של התובעת לשלם לה דמי שימוש עבור השימוש האמור; בתליית שלטי הפרסום, השיגה הנתבעת גבול לשטחי הרכוש המשותף של הבית ופגעה ברכוש המשותף של הבית.
5. טענות ההגנה יפורטו להלן בתמצית:
 - א. עסקינן בתביעה משוללת כל יסוד וחסרת תום לב באופן קיצוני, המהווה שימוש לרעה בהליכי משפט, מאחר והיא הוגשה על רקע סירובה של הנתבעת להיענות לדרישות התובעת לשאת בתשלום דמי ניהול בשיעור גבוה מזה שהוסכם עליו

מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 7/182/2017

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- בהסכמי המכר עם רוכשי דירות הבית, עבור דירות שטרם נמכרו ו/או נמסרו על ידה.
- ב. התביעה הוגשה בהיעדר כל סמכות, ומבלי שהתקבלה הסכמת כל בעלי הדירות להגשתה, ומשכך יש להורות על מחיקתה.
- ג. הנתבעת הציבה שני שלטים על קירותיהם החיצוניים של דירות הפנטהאוזים ותלתה אותם משטח הגג אשר הזכויות בו נותרו בבעלותה עוד בשלב בניית ו/או הקמת הבניין. שלטים אלה הוצבו בהתאם להוראות הסכמי המכר שנחתמו עם כל בעלי הדירות בבית. בהתאם להסכמי מכר אלו, הוצאו הקירות החיצוניים שעל גביהם הוצבו השלטים מהרכוש המשותף, והוצמדו לדירות הפנטהאוז שנותרו בבעלות הנתבעת. התובעת נעדרת כל זכות בקירות אלה, ומשכך יש להורות על מחיקת התביעה בהעדר עילה.
- ד. החלטת הנציגות על הסרת השלטים התקבלה בחוסר סמכות, שכן החלטה מסוג זה צריכה להתקבל ע"י רוב של בעלי הדירות באסיפה הכללית של הבית. עסקינן בהחלטה בטלה מעיקרה, ואין בה כדי לחייב את הנתבעת.
- ה. גם אם קירותיהם החיצוניים של דירות הפנטהאוז מהווים רכוש משותף, אזי הצבת השלטים על גביהם מהווה שימוש סביר בנסיבות העניין.
- ו. הנציגות ובעלי הדירות בבית לא הביעו התנגדות להצבת השלטים, והחלטת הנציגות להסרתם התקבלה כעבור שנה וחצי לאחר מכן. בנסיבות אלה יש לראות בבעלי הדירות בבית ובנציגות כמי שנתנו הסכמה מפורשת או מכללא להצבת השלטים, ולחילופין יש לראותם כמי שראו בהצבת השלטים שימוש סביר ברכוש המשותף.
- ז. התובעת אינה זכאית לדרוש כל פיצוי כספי מהטעמים שפורטו לעיל.
6. מאחר ולא ניתן היה לגשר בין המחלוקות שבין הצדדים, נקבע התיק לשמיעת ראיות, וכל צד הגיש את ראיותיו.
7. במסגרת תצהירי התובעת הצהירו עדיה כי לאחר המועד בו נקבע התיק לשמיעת ראיות, הסירה הנתבעת את השילוט (ראה סעיף 19 לתצהירו של מר מרקוביץ משה וכן סעיף 6 לתצהירו של מר חן אברהם שהעידו מטעם התובעת).
8. לאחר הגשת תצהירים אלו הגישה הנתבעת בקשה לסילוקה של התביעה על הסף (להלן: "הבקשה"), במסגרתה טענה כי עם הסרת השילוט התאיין הסעד העיקרי בתביעה, סילוק יד, והסעד שנוטר, דמי שימוש ראויים, אינו נתון לסמכותה של המפקחת.
- בתגובה טענה התובעת כי לאחר שהוסרו השלטים האמורים הציבה הנתבעת את השילוט מחדש על קירותיו החיצוניים של הבית, ומשכך הסעדים שהתבקשו במסגרת התביעה עומדים בעינם, ודין הבקשה להידחות.
- בהחלטתי מיום 7.5.19 הוריתי על דחיית הבקשה מהנימוקים המפורטים בה.
9. עדי הצדדים נשמעו, כן הוגשו סיכומי הצדדים, ועתה נותר להכריע בתביעה.
- דיון והכרעה**
10. אקדים ואומר כי מצאתי לקבל את התביעה, ונימוקיי יפורטו להלן:

העדר סמכות עניינית

11. אדון תחילה בטענת הנתבעת בסיכומיה, לפיה מאחר שהנתבעת לא תיקנה את תצהירה על מנת לתמוך בטענתה כי הנתבעת שבה והציבה שילוט על קירותיו החיצוניים של הבית, הרי שאין לקבל כל טענה עובדתית חדשה מצדה של הנתבעת הסותרת את הנתען בתצהירה, והמהווה הרחבת חזית, ומשכך, הסעד להסרת השילוט התייטר, ואין המפקחת מוסמכת לדון בסעד שנוטר לחיוב הנתבעת בדמי שימוש ראויים בגין השלטים שהוסרו.

12. דין טענה זו להידחות מאחר ובמסגרת כתב התביעה התבקש להורות לנתבעים "להסיר את שלטי הפרסום שלה מקירות הבניין", ואין הבדל, לדידי, אם המדובר בשילוט שהיה קיים במועד בו הוגשה התביעה או בשילוט שהוצב במהלך ניהולה.

בחקירתו הנגדית העיד מר משה מרקוביץ מטעם הנתבעת, כי הנתבעת שבה והציבה את השילוט (פרוטוקול מיום 2.6.19, עמ' 2, 13-17) ומר שלומי חנין, מנהל פרויקטים אצל הנתבעת אישר את האמור (פרוטוקול מיום 2.6.19, עמ' 5, שורות 38-39).

משעלה מעדויות אלה כי הנתבעת שבה והציבה שילוט על גבי קירותיו החיצוניים של הבית, הרי שאין לומר כי הסעד שהתבקש להסרת השילוט התייטר, ודין טענת הנתבעת להרחבת חזית להידחות.

13. עניין לנו, אפוא, בתביעה שעילתה השגת גבול, ולמפקח על רישום מקרקעין הסמכות לדון בה בהתאם להוראת סעיף 72(ב) לחוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין"). בהינתן שהסעד המתבקש לדמי שימוש הוא פועל יוצא של תביעה להסגת גבול, הרי שבסמכותו של המפקח על רישום מקרקעין לדון גם בסעד שהתבקש לדמי שימוש ראויים. ראה לעניין זה את החלטתי בתיק 135/11, חסאן נ' אטיה (לא פורסם, ניתן ביום 4.3.12):

"משהוסמך המפקח על רישום המקרקעין לדון בתביעה שעניינה הסגת גבול, לא יהיה זה מתקבל על הדעת, לדידי, לקבוע כי הוא נעדר סמכות ליתן תרופה שבצידה של עילת הסגת הגבול. ראה גרינוולד לעיל (ע"א (מחוזי ת"א) 3/98, חנה גרינוולד נ' נעמי סילוני (פורסם בנבו, 28.2.99). נוכח האמור לעיל אני סבורה, כי המפקח על רישום המקרקעין מוסמך ליתן כל "סעד אחר" הנדרש בקשר עם תביעה שעילתה הסגת גבול, לרבות, פסיקת דמי שימוש ראויים. בכך אני מצטרפת לדעתו של חברי כבוד המפקח אורן סילברמן (כתוארו אז) ראה תיק 285/10, נציגות הבית המשותף רחוב סוקולוב 66 רמת השרון נ' שלמה צפרי (פורסם בנבו, 26.2.12), ומאמצת את נימוקיו המפורטים."

14. נוכח האמור לעיל, מצאתי לדחות את טענת הנתבעת להעדר סמכותי לדון בתביעה.

סמכות הנתבעת להגיש את התביעה

15. סעיף 65 לחוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") קובע כי "לכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול ענייני הבית המשותף; הנציגות תיכון ותפעל לפי הוראות התקנון".

16. סעיף 69 לחוק המקרקעין קובע כי: "הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל עניין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה

להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחד בשם כל בעלי הדירות".

17. סעיפים אלו הוחלו בהתאם לסעיף 77ב לחוק המקרקעין על בתים משותפים שטרם נרשמו, ואולם ראויים להירשם ככאלה, כבית מושא התביעה.

18. בע"א 98/80, נציגות הבית המשותף נ' קדמת לוד בע"מ (פורסם בנבו, 27.9.81) מפרט בית המשפט את תפקידי הנציגות וסמכויותיה כדלקמן:

"נציגות הבית המשותף, הנבחרת על ידי האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף, היא הגוף המבצע של הבית המשותף, שמתפקידו לטפל בכל העניינים הכרוכים בתחומים המשותפים לכל הדיירים. מטבע הדברים הכוונה לניהול פנימי השוטף של הבניין, ובעיקר בכל הנוגע לרכוש המשותף, אופן השימוש בו, החזקתו התקינה, ביצוע תיקונים בשעת הצורך, גביית הוצאות ההפעלה השונה וכדומה. החוק הקנה לנציגות הבית המשותף לצורך ביצוע תפקידיה מעמד משפטי מיוחד: על פי האמור בסעיף 69 הנ"ל ניתנת לנציגות הבית המשותף בתור שכזו כשרות להיות צד לפעולות משפטיות שונות. אולם כשרות זו מוגבלת ומסויגת בסעיף עצמו, התוחם את גבולותיה לעניינים הנוגעים להחזקתו התקינה וניהולו של הבית המשותף".

19. נציגות הבית המשותף, אפוא, לטפל בכל העניינים הנוגעים להחזקתו, לתפקודו ולשימושו של הרכוש המשותף, ואף לנקוט בהליכים משפטיים בכל הנוגע לעניינים הללו.

20. יוצא אפוא, כי במסגרת תפקידה של הנציגות לפעול לשמירת הרכוש המשותף הבית, מוסמכת היא להגיש תביעה כנגד בעל דירה שהסיג גבול לרכוש המשותף, ואין הדבר מותנה בקבלת הסכמת של כל בעלי הדירות בבית או בקבלת החלטה של האסיפה הכללית.

21. פסק הדין שניתן במסגרת בש"א 16863/03, משה בן דוד חברה לבניין בע"מ נ' נציגות הבית המשותף (פורסם בנבו, 4.2.04) אליו הפנתה הנתבעת בסיכומיה לצורך תמיכה בטענתה כי נדרשת הסכמת כל בעלי הדירות בבית להגשת התביעה, אינו רלוונטי לעניינו, בשים לב לכך שהתביעה שם הוגשה ע"י נציגות בית משותף כנגד הקבלן שבנה את הבית בגין ליקויי בניה בעילה חוזית הנוגעת למישור היחסים שבין כל אחד מרוכשי הדירות לבין הקבלן.

תביעה, כזו, כעולה מפסק הדין בעניין משה לעיל, אינה נוגעת "לעניינים הנוגעים להחזקתו התקינה וניהולו של הבית המשותף", ואינה נכנסת לגדרה של הסמכות שהוענקה לנציגות. זאת, בשונה מתביעה זו שבפני, כמפורט לעיל.

22. נוכח האמור לעיל, מצאתי לדחות את טענת הנתבעת כי התובעת נעדרת סמכות להגיש את התביעה.

מהו מעמדם של הקירות החיצוניים שעל גביהם הוצב השילוט?

23. בין הצדדים קיימת מחלוקת בשאלה מהו מעמדם של הקירות החיצוניים של הבית. בעוד שלטענת הנציגות הקירות החיצוניים של הבית נכללים ברכוש המשותף של הבית טוענת הנתבעת כי הקירות החיצוניים של דירות הפנטהאוז הוצאו מהרכוש המשותף והוצמדו לדירות אלה. מהו אם כן מעמדם של קירות אלה?

24. משטרם נרשם הבית כבית משותף, ואין, כאמור, מחלוקת בין הצדדים כי הוא ראוי להירשם ככזה, אזי חלים על הבית הוראות פרק ו' לחוק המקרקעין.

25. סעיף 77א לחוק המקרקעין מגדיר מהו רכוש משותף בבית שטרם נרשם כבית משותף כדלקמן:

"רכוש משותף" – כל חלקי הבית חוץ מהדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים (הדגשה שלי א.ש.) המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים וכן מתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסוימת".

26. הינה כי כן, הקירות החיצוניים נכללים בהגדרה של רכוש משותף בהתאם לסעיף 77א לעיל. עתה יש לבחון האם קירות אלה נגרעו כדין מהרכוש המשותף והוצמדו לדירות הפנטהאוז שבבעלות הנתבעת.

27. הוראת החוק הרלבנטית בעניין זה היא סעיף 6 לחוק המכר (דירות), תשל"ג-1973 (להלן: "חוק המכר (דירות)") הקובעת את התנאים שבהם נדרש לעמוד מוכר דירה, כהגדרתו בסעיף 1 לחוק, אם ברצונו להוציא חלקים מן הרכוש המשותף. וכך קובע הסעיף:

"(א) המוכר דירה בבית משותף או בבית המיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנה הוראה של התקנון המצוי המתייחס לעניין מן העניינים המנויים להלן, חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזה המכר פרטים על אותו עניין, ואלה העניינים: (1) הוצאת חלק מן הרכוש המשותף; (הדגשה שלי, א.ש.) (3) שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו; (4) סדרי קבלת ההחלטות בדבר ניהול הבית המשותף; (5) כל עניין אחר שקבע שר השיכון בצו בדרך האמורה בסעיף 3 (א). (ב) מוכר שלא מסר פרטים על עניין מהעניינים המנויים בסעיף קטן (א) יראוהו, על אף האמור בחוזה המכר, כמי שהתחייב שהוראות התקנון המצוי לגבי אותו עניין יחולו על הבית המשותף".

28. מוכר דירה, ובענייננו - הנתבעת (אשר בנתה את הבית, ומכרה את דירותיו), המבקשת להוציא חלקים מן הרכוש המשותף חייבת, אפוא, ליתן לכך ביטוי מפורש וברור במפרט המצורף להסכם המכר או לצרף לחוזה המכר פירוט מדויק המתייחס לאותם חלקים. הסעיף נועד לוודא כי הזכויות אותן רוכש הקונה לא רק הובאו לידיעתו אלא גם הובנו על-ידו, ולמנוע מצב בו המוכר מסתיר את כוונותיו האמיתיות מאחורי אמירות כלליות וניסוחים מעורפלים או על-ידי "הבלעת" עניינים מהותיים להתקשרות אשר להם משמעות כספית חשובה (ראו: ע"א 118/78, גוב ארי חברה לבנין ולהשקעות בע"מ נ' כהן, פ"ד לג(1) 805, ע"א 60/80, שטרן נ' מאירי יצחק חברה קבלנית לבתים משותפים לבנין בע"מ, פ"ד לו(3) 48, ע"א 3017/92 מרדר נ' כרמלי, [פורסם בנבו, 7.8.95]).

29. בע"א 213/80, שמענונו נ' ברוכים, פ"ד לו(3) 808, עמד כב' השופט אלון על מטרתו של חוק המכר (דירות) ועל הצורך בהקפדה יתרה עם הקבלן - בקטנה כבגדולה - בכל הנוגע לקיום דרישותיו של החוק:

"מטרתו של חוק המכר (דירות) היא להביא לידיעת הקונה, בצורה ברורה ומובנת – וללא הסתתרות וערפול מאחורי אמירות כלליות וגורפות ומבלי להבליע גופי דברים, שלהם משמעות כספית חשובה, בתוך ריבוי דברים טפלים ובלתי חשובים – מה הן כוונותיו האמיתיות של המוכר, ומה הן הזכויות אשר הוא, הקונה, רוכש הימנו ... כדי

להבטיח שאכן הובאו הדברים לידיעת הקונה והובנו על-ידי, חובה היא על המוכר לצרף לחוזה מיפרט, ובו תיאור הדירה וכל הכלול בה ... ואם מבקש המוכר לשנות מן התקנון המצוי בקשר לזכויות שבבית המשותף, חייב שינוי זה להופיע במפורש במיפרט הנ"ל או במסמך המצורף לחוזה ובו פרטים בקשר לשינוי זה. ייחוד והבלטה אלה מטרתם להסב את שימת לבו של הקונה לשינויים אלה. הצורך בהגנה מיוחדת זו על קונה הדירה נובע ממעמדו הנחות של הקונה מבחינת כוח המיקוח, יכולת התמרון וניסוח החוזה לעומת הקבלן בונה הדירה, וזאת כאשר מדובר במצרף חיוני ביותר, הן לפרט והן מבחינת האינטרס הציבורי והחברתי, ובסכומי כסף ניכרים וגדולים".

וראו בעניין זה גם דברים דומים שנאמרו בע"א 238/83, נציגות הבית המשותף נ' מרכוס, פ"ד מא(2) 561.

30. עוד קבעה הפסיקה כי גריעה מהשטח המשותף חייבת להיעשות באופן קונקרטי ומפורש בכתובים. אין די בקיום הוראה כללית בחוזה המכר המותירה בידי הקבלן המוכר שיקול דעת לגרוע בעתיד שטחים מהרכוש המשותף בלא פירוט קונקרטי של שטחים מוגדרים. תיאור החלקים המוצאים מהרכוש המשותף צריך אפוא להיות מדויק ומפורט (ראה רע"א 259/99, חב' פליצ'ה ראובן בע"מ נ' סופיוב, פ"ד נה(3) 385, בעמ' 402, ע"א 3902/98 מיאב חברה קבלנית לבנין בע"מ נ' סטולר, פ"ד נד(1) 849, בעמ' 858; וכן: מ' דויטש, קנן, כרך א' 684).

31. ולמקרה שלפנינו: לטענת הנתבעת הקירות החיצוניים של הבית שעל גביהם הוצב השילוט נגרעו מהרכוש המשותף, וזאת בהתאם לסעיף 6.4 להסכמי המכר שחתמה עם רוכשי דירות הבית (הסכם מכר לדוגמא צורף לכתב ההגנה וכן לתצהירי הנתבעת) המורה כדלקמן:

"החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לכלול במסגרת הרכוש המשותף חלקים בלתי בנויים בפרויקט, שטחים בנויים, קירות חיצוניים, חצרות פרטיות, גינות, מרפסות מקורות ומרפסות לא מקורות, חדרי טרנספורמציה בזק ותקשורת, שטחי חניה, מחסנים ושטחי אחסון, שטחים ומתקנים המשמשים בלעדית יחידה או יחידות מסוימות בבניינים, גגות, שבילים, מעברים, דרכי גישה, שטחים בקומת הכניסה, ובמרתפים התת קרקעיים, וכל שטח אחר הניתן להוצאה מהרכוש המשותף לפי חוק המקרקעין ו/או כל דין אחר".

32. עסקין בהוראה כללית וגורפת, ללא התייחסות ספציפית, המותירה בידי המוכר שיקול דעת לגרוע בעתיד שטחים מהרכוש המשותף בלא פירוט קונקרטי המתייחס לגריעת הקירות החיצוניים של דירות הפנטהאוז מהרכוש המשותף של הבית, תוך השארת שיקול דעת רחב בעניין זה לנתבעת.

33. יתירה מכך, סעיף 6.5 להסכם המכר בו פורטו החלקים אשר נגרעו באופן מפורש מהרכוש המשותף, מורה כדלקמן: "מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומהוראות המפרט, נספח א', מאשר הקונה שנמסר לו על ידי החברה כי השטחים המפורטים להלן לא יכללו במסגרת הרכוש המשותף". בסעיפים 6.5.1 - 6.5.5 פורטו החלקים אשר נגרעו במפורש מהרכוש המשותף, והקירות החיצוניים של דירות הפנטהאוז אינם נמנים עליהם.

34. כמו כן, מפרט דירות הפנטהאוז המצוין בסעיף 6.5 לעיל, לא צורף. לא נטען, וממילא לא הוכח, כי במפרט האמור הוצמדו הקירות החיצוניים של דירות הפנטהאוז לדירות אלה. עיון בשאר סעיפי הסכם המכר מלמד כי אין כל התייחסות ספציפית לגריעת הקירות החיצוניים מהרכוש המשותף.

35. נוכח כל האמור לעיל, מצאתי לדחות את טענת הנתבעת כי הקירות החיצוניים של דירות הפנטהאוז הוצמדו לדירות אלה. לאור האמור, יש לראות בקירות אלה שעל גביהם נתלה השילוט כחלק מהרכוש המשותף של הבית.

36. עד הנתבעת, מר שלומי חנין, הפנה בתצהירו לסעיף נוסף בהסכם המכר וטען כי גם אם הקירות החיצוניים נכללים ברכוש המשותף, הרי שהנתבעת רשאית להציב עליהם שילוט בהתאם לסעיף 6.15.2 הקובע כדלקמן (ראה סעיף 9 לתצהירו של מר שלומי חנין):

"6.15.2 החברה תהיה רשאית לרשום תקנון מיוחד לבית המשותף, בהתאם לסעיף 62 לחוק המקרקעין....ולכלול בתקנון הבית המשותף את ההוראות הבאות:

...6.15.1

6.15.2 הוראות הקובעות את אופן ההתנהגות בשטחי הרכוש המשותף ובכלל זה הוראות האוסרות להניח כל מיטלטלין שהם ו/או לקבוע שלטים בשטחי הרכוש המשותף, למעט במקומות שאושרו ע"י החברה ו/או הנציגות ו/או חברת הניהול והוראות האסורות הפרעה והטרדה של יתר מחזיקי היחידות בבית המשותף."

37. מאחר וטענה זו הועלתה, לראשונה, בתצהירי הנתבעת, מצאתי לקבל את טענת התובעת, ולהורות על דחייתה בשל הרחבת חזית אסורה. ראה לעניין זה אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה 2015), עמ' 145:

"משקבעו בעלי הדין את רשימת הפלוגות העומדות לדיון, גודרת רשימה זו את הסוגיות שבהן ידון בית המשפט, ואין להרחיב את הדיון לשאלות משולבות של עובדה ומשפט שלא נכללו באותה רשימה.... רשימת הפלוגות העומדת לדיון מעוצבת בכתבי הטענות של בעלי הדין. משכך, טענה שמעלה בעל דין שלא הועלתה מלכתחילה בכתבי טענותיו מהווה שינוי חזית, ויש לדחותה."

38. למעלה מן הדרוש, מצאתי לדחות את הטענה גם לגופה, שכן הסעיף מקנה לנתבעת את הזכות לרשום תקנון מוסכם, ולכלול בו הוראות שונות, בין היתר, הוראות הנוגעות להצבת שלטים בשטחי הרכוש המשותף של הבית. אין חולק כי תקנון מוסכם לבית טרם נרשם, ומשכך אין הסעיף רלבנטי לענייננו. לכך יש להוסיף את העובדה שספק בעיני גם אם מדובר בסעיף ספציפי ומסוים העומד בהוראות סעיף 6(א) לחוק המכר (דירות) והפסיקה שהובאה מכוחו.

39. כמו כן, הסמכות לקבוע את סדרי ניהול הבית המשותף בהתאם לתקנון המצוי החל על בית שטרם נרשם מכוח הוראת סעיף 77 לחוק המקרקעין, נתונה לאסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית. בהתאם להוראת סעיף 6(א) (ב) לחוק המכר (דירות) שצוטט לעיל, והפסיקה שהובאה לעיל, סטייה מהוראה זו, מחייבת כי הסעיף יופיע בכל הסכמי המכר שנחתמו עם רוכשי הדירות, וזאת לא הוכח לפני. ראה לעניין זה פס"ד בעניין מרכוס לעיל:

"עדיין יש לבחון אם קוימו הוראות חוק המכר (דירות) כלפי כל יתר רוכשי הדירות. די יהיה בכך אם לא קוימו רק כלפי אחד מהרוכשים כדי להכשיל את ההתחייבות כלפי המשיבים ואזי, על סעיף 6 (ב), יראו את הקבלן כמי שהתחייב שהוראות התקנון המצוי יחולו על הבית המשותף."

40. נוכח כל האמור לעיל, דין טענת הנתבעת כי היא רשאית להציב שילוט בשטחי הרכוש המשותף מכוח הוראת סעיף 6.15.2 להסכם המכר להידחות אף לגופה.

הצבת השילוט האם שימוש סביר ברכוש המשותף או פגיעה בו?

41. סעיף 2 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין (להלן: "התקנון המצוי"), החל גם על בית שטרם נרשם כבית משותף בהתאם להוראת סעיף 77ג לחוק האמור קובע כדלקמן:

"(א) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה.

(ב) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת.

(ג) כל שינוי או תיקון אחר רשאי בעל דירה לעשות בדירתו על דעת עצמו."

42. בע"א 136/63, לווינהיים נ' שורצמן, פ"ד י"ז(3), 1722, נקבע: אין בעל דירה רשאי לעשות שינויים או תיקונים בדירתו הפוגעים ברכוש המשותף אלא אם קיבל הסכמת האסיפה הכללית, ואין נפקא מינה אם הפגיעה היא קטנה או גדולה וניתנת לפיצוי נאות או לא" (שם בעמ' 1725).

43. הנה כי כן, התקנון המצוי אוסר על בעל דירה לעשות בדירתו שינויים הגורמים ל"פגיעה" ברכוש המשותף או בדירה אחרת. המונח "פגיעה" התפרש בפסיקה באופן רחב, ולא כפגיעה פיסית דווקא.

44. שאלת ה"פגיעה" נבדקת, בין היתר, בהתאם לתנאי המקום והזמן. בתוך כך, יש צורך לעמוד על אופי וצביונו המיוחד והייחודי של הבית המשותף, ולתת את הדעת לסממנים ואלמנטים ייחודיים, כגון מיקום, גובה, גיל וכיוצא באלו. מובן מאליו, אפוא, כי בשים לב להבדלים אלו, אותה התקנה ממש יכולה להיחשב כ"פגיעה" בבית משותף אחד ולא תחשב לפגיעה בבית משותף אחר. כך למשל, אין דין שינויים הנעשים על פני קיר חיצוני מרובה צינורות והתקנות חיצוניות כדן שינויים בבית שחזיתו "נקיה" מתוספות או מצינורות. מובן, כי בעוד התקנה על גבי קיר חיצוני בבניין הראשון עשויה ל"היבלע" במראהו החיצוני הבלתי אחיד של הבית המשותף, בבניין השני היא עשויה להזיק למראהו באופן מובהק.

45. לעומת זאת, שימוש ברכוש המשותף שהוא בבחינת שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף אינו מחייב הסכמת כל בעלי הדירות בבית, ובלבד שהשימוש שנעשה ברכוש המשותף הוא רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן, וכן אינו מונע שימוש דומה מאחרים. ראה לעניין זה ע"א 549/73, וינטרס נ' זמורה, פ"ד כח(1), 645, המ' 163/81, בודנוף נ' נציגות הבית ברחוב שחראי 14-18, י-ם, פ"ד לה (4), 277, ע"א וילנר נ' גולני, פ"ד מב(1), 49.

46. על מבחן הסבירות נאמר בספרו של נרקיס, הבית המשותף, מהדורה רביעית, הוצאת אוצר המשפט, בעמ' 152: "שימוש סביר" הינו סוג של שימוש ברכוש המשותף שעונה על הצרכים הלגיטימיים של בעלי הדירות בבית המשותף והן של אפשרות הקיום בו בצורה נאותה ומתקבלת על הדעת. שימוש שכזה צריך שיהיה סביר לפי תנאי הזמן והמקום."

47. ובמקרה שלפנינו, עסקינן בהצבת שילוט פרסומי למכירת דירות הפנטהאוז של הנתבעת על גבי הקירות החיצוניים של הבית, שאין חולק כי נועד למגורים. בשים לב לאופיו

ויעודו של הבית, ובשים לב לכך שלא מוצבים שלטים נוספים ע"י יתר בעלי הדירות בבית (ראה עדותו של מר משה מרקוביץ מטעם התובעת, פרוטוקול מיום 2.6.19, עמ' 2, שורות 30-31, שלא נסתרה) הרי שהצבת השילוט, כאמור, תוך פרסום שמה של הנתבעת כחברת בניה ופרסום לדירותיה, אינה מהווה שימוש סביר ברכוש המשותף.

48. הצבת השילוט, כאמור, פוגעת בחזונו החיצוני של הבית ומהווה פגיעה ברכוש המשותף כהגדרתה בסעיף 2(א) לתקנון המצוי המצריכה את הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית עוד טרם הצבת השילוט.

49. מר שלומי חנין אישר בחקירתו הנגדית כי לא זומנה אסיפה כללית לאישור הצבת השילוט, וממילא לא התקבלה החלטה באסיפה הכללית המאשרת זאת (ראה פרוטוקול מיום 2.6.19, עמ' 7, שורות 43-44).

50. טענה הנתבעת כי הנציגות ובעלי הדירות בבית לא הביעו התנגדות להצבת השלטים, והחלטת הנציגות להסרתם התקבלה כעבור שנה וחצי לאחר מכן. בנסיבות אלה יש לראות, כך לטענת הנתבעת, בבעלי הדירות בבית ובנציגות כמי שנתנו הסכמה מפורשת או מכללא להצבת השלטים. דין טענה זו להידחות:

מתצהירי התובעת עולה כי הנתבעת הציבה את השלט הראשון כשהבית טרם אוכלס, וטרם שמונתה נציגות לבית, וכי לאחר שמונתה הנציגות הציבה הנתבעת שלט נוסף (ראה סעיפים 6-7 לתצהירו של מר מרקוביץ מטעם התובעת). עוד עולה מעדותו של מר מרקוביץ כי בסמוך להצבת השלט השני פנתה התובעת לנציגות בדרישה להסרת שני השלטים (ראה סעיפים 8-10 לתצהירו). עדותו זו לא נסתרה.

הוכח, אפוא, באשר לשלט הראשון כי לא יכולה הייתה להינתן הסכמת הנציגות ובעלי הדירות להצבתו, שכן הבית טרם אוכלס, והנציגות טרם מונתה.

באשר לשלט השני, הוכח כי הנציגות הביעה התנגדות להצבתו בסמוך להצבתו, ואף פעלה להסרתו, ומשכך דין טענת הנתבעת כי ניתנה הסכמה להצבתו להידחות.

יתירה מכך, נמצא כמפורט לעיל, כי שלטים אלה הוסרו במהלך ניהול ההליך ושלט אחר הוצב במקומם. לא נטען, וממילא לא הוכח כי ניתנה הסכמה של בעלי הדירות באסיפה הכללית של הבית להצבתו של שלט זה.

51. מכל מקום, גם אם הייתה מתקבלת טענת הנתבעת כי במשך שנה וחצי לא הביעו בעלי הדירות בבית והנציגות התנגדות להצבת השילוט, הרי שאין בכך כדי להעיד כי ניתנה על ידם הסכמה מכללא להצבת השלטים, שכן הסכמה מכללא משתכללת במקרה של שתיקה המתפרשת למשך שנים. ראה ת"א (מחוזי – ת"א) 2816/03, קונצ'צקי נ' שפלן (פורסם בנבו, 3.4.06):

"בהסקת מסקנות בדיעבד בדבר אישור השימוש הייחודי בגג הבית המשותף יש משום הגמשה של כללי ניהול הבית המשותף, שלילת הוודאות ומתן אפשרות ליצירת זכויות על ידי קביעת עובדות בשטח. אישור שכזה מנוגד לתכלית הראויה... ואולם, גם בהנחה המיטיבה עם המשיבים ששתיקת המערערים במשך השנים מהווה מתן הרשאה לשימוש הייחודי שאותו עשו בגג הבית, הרי לכל היותר אפשר לראות את השימוש כנעשה בגדר הדוקטרינה של "רישיון במקרקעין" ללא תמורה. כפי שנפסק לא אחת, הרשאת חינוס שכזו ניתנת לביטול עם גילוי דעתו של המקנה שאין ברצונו להמשיך בהענקת הרישיון...".

"שתיקה" לפרק זמן של שנה וחצי אינה יוצרת "הסכמה מכללא", וממילא רשאים היו נציגות הבית ובעלי הדירות בבית להפסיקה בכל עת.

52. מצאתי לדחות את טענת נתבעת כי החלטת הנציגות לפעול להסרת השלטים בטלה, מאחר והחלטה, כאמור, הינה בסמכותה של האסיפה הכללית של הבית. כמפורט לעיל, היה על הנתבעת לקבל את אישורה של האסיפה הכללית להצבת השילוט עוד טרם הצבתו. משהציבה הנתבעת את השילוט בלא שהתקבלה החלטה באסיפה הכללית המאשרת זאת, הרי שבסמכותה של נציגות הבית, במסגרת תפקידה לשמירת הרכוש המשותף של הבית, לפעול להסרת השילוט, ולפנות לנתבעת בדרישה להסרתם בהתאם להחלטתה מיום 24.4.17.

דמי שימוש ראויים

53. התובעת צירפה את חוות דעתו של מר דרור עדן לצורך הוכחת סכום דמי השימוש הראויים עבור הצבת השילוט.

54. בחקירתו הנגדית הודה מר עדן כי הוא אינו מומחה בתחום (ראה פרוטוקול מיום 2.6.19, עמ' 4, שורות 5-6), וכי לצורך הכנת חוות דעתו הסתמך על הצעת מחיר שהועברה לו ע"י "פיני" אשר עובד בחברה זכיינית העוסקת בפרסום שלטים (ראה פרוטוקול מיום 2.6.19, עמ' 4, שורות 11-14).

55. בהמשך חקירתו הנגדית הודה מר עדן כי הצעת המחיר אותה קיבל מ"פיני", ואשר עליה הוא ביסס את ממצאיו, אינה ההצעה המדויקת, וכי יש בידו הצעת מחיר מדויקת של "פיני", שלא צורפה לחוות דעתו, ולא הוגשה (ראה פרוטוקול מיום 2.6.19, עמ' 4, שורות 31-34).

56. בשים לב לכך, שמר עדן ביסס ממצאיו בהסתמך על הצעת מחיר אותה קיבל מצד שלישי, שלא ברור מהי הכשרתו ומהו תחום מומחיותו ובהסתמך על אילו נתונים גיבש את הצעת המחיר הנטענת, ובשים לב לכך שמר עדן הודה כי הצעת המחיר הנטענת עליה ביסס, כאמור, את חוות דעתו אינה הצעת המחיר המדויקת, לא מצאתי ליתן לחוות דעת זו, כל משקל ראיתי.

57. פועל יוצא הוא שהתובעת לא הוכיחה את תביעתה לתשלום דמי שימוש ראויים, ומצאתי לדחותה.

58. אשר על כן, ונוכח כל האמור לעיל, מצאתי לקבל את התביעה, ולהורות לנתבעת להסיר, על חשבונה, בתוך 30 ימים מהיום את השילוט אותו הציבה על קירותיו החיצוניים של הבית, ולהשיב את מצב הקירות לקדמותם. כן אני מורה לנתבעת לשלם לתובעת סך של 9,000 ש"ח עבור הוצאות ההליך הכוללות שכ"ט עו"ד. סכום זה ישולם בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן, יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן בלשכתי בהעדר הצדדים היום, 27 במאי, 2020, ד' סיון, תש"פ. עותק יומצא.

אסתי שחל
מפקחת על רישום מקרקעין
נתניה